

大法官講堂：
中華民國憲法及政府（一）

第二十三講
不受軍事審判
& 居住遷徙自由

授課教師：湯德宗教授
國立臺灣大學政治學系



【本著作除另有註明外，採取創用 CC「姓名標示
—非商業性—相同方式分享」臺灣 3.0 版授權釋出】

不受軍事審判 & 居住遷徙之自由

湯德宗

憲法有聲書

目 次

壹、軍事審判與人身自由

一、憲 §8, 9, 16, 77 間之體系關連（體系解釋）

1. 憲 §9 肯認「軍事審判」制度之存在

1.1 「軍事審判」指由軍事法庭（court-martial）所為之審判 v.

1.2 「司法審判」指由普通（文人）法院（civil court）所為之審判

2. 憲 §9 乃憲 §8 之例外規定

2.1 林紀東：「蓋現役軍人，本應包括於第八條所稱『人民』之內，亦受該條之各種保障，惟因本條規定之故，於其犯陸海空軍刑法或其特別法之罪時，遂不適用第八條之規定，得由軍事審判機關加以審問處罰矣」

林紀東，《中華民國憲法逐條釋義》，頁 133~134。

2.2 徵諸美國聯邦憲法增修條文第五條之規定，林氏所見益真

Ω 按美國憲法增修條文第四條、第五條、第六條與第八條皆在保障被告的基本人權，合稱「被告人權條款」（a “bill of rights” for accused persons）。增修第五條旨在保障「人民」非經大陪審團（grand jury）提起公訴，不受死罪或不名譽之罪之審判，但「發生於陸、

海軍的案件」除外（亦即軍事審判無需經大陪審團起訴）。軍事審判遂有別於普通法院審判。

3. 憲 §9 所保障者，不僅「唯有現役軍人始得接受軍事審判」，且「軍事審判亦受正當程序之保障」；甚至「現役軍人犯罪亦不必然受軍事審判」

- 3.1 憲法承認軍事審判制度，且默許其得適用與一般法院不同之審判程序，然非謂軍事審判即可忽視被告之人權保障

Ω 憲法第九條既列於憲法第二章中，復列在憲法第二十三條之前，是軍事審判對軍人人權之限制，自仍須受憲法第二十三條「比例原則」之拘束。蓋軍人亦人民，僅因其從事之工作性質特殊，而受軍事審判；軍事審判僅能在為達成軍事目的所必要之範圍內，合理限制軍事被告之訴訟權。

4. 軍事審判之確定終局判決有違憲之疑義者，仍得聲請大法官解釋，以維司法權之統一（縱審判體系未必統一）

- 4.1 憲法第七十七條規定：「司法院為國家最高司法機關，掌理民事、刑事、行政訴訟之審判、及公務員之懲戒」。
憲法第七十八條規定：「司法院解釋憲法，並有統一解釋法律及命令之權」。

- 4.2 軍事審判體系隸屬於司法院外，乃制憲者有意之安排

- 4.3 制度衡平

按相關解釋，司法權未必皆須由法官（普通法院）行使，但終須有至少一次使用（普通）法院（受審）的機會

- 釋字 362（軍人過犯除彈劾案成立者外，仍由軍事長官依陸海空軍懲罰法行之）

23〈不受軍事審判 & 居住遷徙自由〉講綱

- 釋字 298（輕微的文官懲戒處分得由長官為之）
- 釋字 272（動戡時期國安法第九條第二款規定，因已有再審與非常上訴制度，兼顧人民權益，合憲）
- 釋字 160（民事訴訟法上訴第三審之金額限制規定，合憲）

二、軍事審判之適用

1. 平時（§ 9；釋字 436, 704）v.
2. 戰時
 - 2.1 戒嚴法 §8（得自行審判或交普通法院審判）
 - 2.2 陸海空軍刑法 §2（非現役軍人戰時觸犯軍刑法，亦需送軍法審判）（釋字 272）

三、軍事審判與普通審判之差異

1. 程序法不同：刑事訴訟法 v. 軍事審判法（45/07/07）
2. 審級不同
 - 三級三審（刑訴法 §§ 375, 376 & 377） v.
 - 二級二審（軍審法 §187）
3. 審判獨立程度不同
 - 3.1 軍審法 §§18 ~ 20（軍法官保障）；§160（軍事法庭獨立審判）
 - 3.2 軍審法 §158（軍事法庭組成需經核定）
 - 3.3 軍審法 §148-I（不起訴處分書呈核）；§154-I（起訴書呈核）
 - 3.4 軍審法 §133（判決書呈核 與 發交覆議）

四、釋字 436

Q 軍事審判機關隸屬國防部，違憲？

1. 定性

本件為單純憲法疑義（其時之軍事審判制度違憲）？

2. 爭點（疑義）

2.1 依「權力分立原則」(Doctrine of Separation of Powers)，
所有審判機關均須隸屬於司法院（司法體系）？

2.2 軍事審判被告之基本人權因軍事審判權之隸屬於行政
院（非司法院）而遭受侵害？

Ω 後者（基本人權保障問題）實為關鍵，前者（權力分立
問題）僅屬關連而已。

3. 程序問題（參●9講）

Q 本件聲請合乎受理要件？

Q 「疑義」須臻於「成熟」(ripe)，始得受理解釋？

4. 解釋要旨

4.1 現役軍人亦人民

4.2 軍事審判機關對軍人犯罪並無專屬審判權

Q 指於「平時」？抑或兼及「戰時」？

4.3 軍事審判亦需符合「正當法律程序」之最低要求

4.4 平時「宣告有期徒刑以上案件，應許被告以判決違背
法令向普通法院請求救濟」，系爭軍審法規定限期失效

「戰時」應如何？

Q 何以限於「判決違背法令」，始得請求普通法院救濟？

Q 所謂「救濟」，相當於上訴第三審(民訴 §§467, 468)？

Q 普通法院僅能為「法律審」？

Q 大法官應指示具體之修法內容？抑或應僅抽象之原
則？

5. 個別意見書（大法官造法之比較）

5.1 陳計男大法官協同意見書

23〈不受軍事審判 & 居住遷徙自由〉講綱

5.1.1 「戰時」得限制人民司法權之保障（普通人民亦可受軍事審判），但死刑、無期徒刑之判決仍應依職權送司法審查

5.1.2 關於軍人平時受有期徒刑之判決得為司法救濟之宣示，逾越「憲法解釋權限」，但「期之殷，責之切」，尚可贊同。

5.1.3 「受有期徒刑之判決」應非唯一劃分軍、司法終審之標準

Q 何謂也？大法官「造法」有危險（slippery slope）？

5.2 董翔飛大法官協同意見書

5.2.1 釋字 262 釋示軍人懲戒亦屬司法權之範圍，準此，軍事審判應移交司法院所屬法院掌理

5.2.2 軍審法第十一條（國防部為最高軍事審判機關）嚴重違背權力分立原則，應移交司法院所屬法院管轄。多數意見乃「藕斷絲連、欲斷還留」。

5.3 王澤鑑大法官協同意見書

5.3.1 許被告以判決違背法令為由，向普通法院請求救濟，僅屬階段性軍事審判建制，非將軍事審判之司法化固定於此規範模式。在此基準上仍有立法形成之空間，而其最終完成應在貫徹司法化之軍事審判制度

Q 大法官是立法者，抑或司法者？兩者權力應如何劃分？

Cf. 釋字 704〈湯德宗大法官協同意見書〉

5.3.2 鑑於本件解釋具憲法解釋方法論上之意義，爰提出協同意見書

5.4 孫森焱大法官部分不同意見書

5.4.1 所謂「平時受有期徒刑以上之判決」可請求司法救濟，其依據為何？

Q 大法官以憲法解釋「造法」之界限？

5.4.2 既謂「軍審亦國家刑罰權之一種」，則應歸軍審之案件，關於何罪名、何審級，應歸普通法院受理，應屬立法權自由形成之範圍

Q 本件何以名為「部分不同意見」？

5.4.3 實務上，審級調整有困難（審級不對稱）？

5.4.4 重點應在改進軍審程序，而非上訴司法法院

Q 其然乎？

5.5 林永謀大法官部分不同意見書

5.5.1 國家刑罰權之實現，原可就身分、事物之不同，而異其程序

Q So？

5.5.2 所謂「平時受有期徒刑以上之判決，可請求司法救濟」，於理不合，勢難實現

5.5.3 所謂上訴「普通法院」，究指哪一審級？

5.5.4 未論及軍審機關構成員之改進，亦有未恰

📖 湯德宗，〈大法官解釋不同意見的實證研究〉，《權力分立新論 卷二：違憲審查與動態平衡》，頁 449～453（2005 年）

6. 後續追蹤

88/10/02 軍事審判法 修正：

6.1 軍法機關改採地區制，不再隸屬部隊

刪除原 §§9, 10, 11，修正原 §8，將軍事法院分為三級：地方軍事法院、高等軍事法院、最高軍事法院

23〈不受軍事審判 & 居住遷徙自由〉講綱

6.2 取消軍事長官之判決核定權（原軍審法 §133-I, II）及覆議權（原軍審法 §133-III, IV）

Cf. 原 §133→ 新 §128

6.3 取消軍事長官之法庭組成核定權

Cf. 原 §158-I→ 新 §151

6.4 厲行審檢分立

新增 §§49 ~ 56，並刪除原 §§57 ~ 60

6.5 廢除軍官參審制

刪除原 §34

6.6 軍法覆判案件得上訴最高法院或高等法院

新增 §181：

「…

III 被告不服最高軍事法院宣告有期徒刑以上，或高等軍事法院宣告死刑、無期徒刑之上訴判決者，得以判決違背法令為理由，向最高法院提起上訴。

IV 被告不服高等軍事法院宣告有期徒刑之上訴判決者，得以判決違背法令為理由，向高等法院提起上訴。

V 對於前項高等法院之判決，不得再上訴。」

6.7 偵查中得選任辯護人（§69-I）

6.8 擴大審判官迴避事由（§§63, 64）

6.9 羈押決定權移歸軍事法院（§98-II）

6.10 增訂「證據」專章（§§116 ~ 125）

📖 謝添富 & 趙希華，〈修正軍事審判法論釋〉（台北：謝添富出版，2004 年）

五、釋字 704

Q 軍事審判官應為憲法第八十一條之法官，並享有終身職保障？軍事審判官應概以文職任用？

1. 陸海空軍軍官士官服役條例第十七條及陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則（91/11/27 修正發布）第七條，關於後備役軍官經軍法官特考及格，取得軍法官資格後，須申請志願留營經核可，始得續任至（其官階之）最大服役年限（齡）之部分，有違憲法第八十條審判獨立之憲政原理及憲法第十六條保障人民訴訟權之本旨，應自本解釋公布之日起，至遲於屆滿二年時失效。

1.1 系爭軍事審判官續任核可之規定，何以違憲？

- 1.2 為維護審判獨立，軍法官應享有一定之身分保障
解釋文所稱「上開類型軍事審判官」指「後備役常備軍官及後備役預備軍官」而言；所謂「一定之身分保障」指「非受刑事或懲戒處分、監護宣告，或有法律列舉之不適任審判之原因，並經正當法律程序，不得免職」。

1.3 「憲法解釋」與「立法裁量」之分工

「憲法所要求」（軍事審判亦應符合正當程序之最低要求）≠「非憲法所不許」（例如：將軍法審判改隸於司法院，並使軍法官概為憲法第八十條（獨立審判）與第八十一條（終身職保障）之文職法官，乃屬立法裁量之空間）

📖 釋字 704〈湯德宗大法官協同意見書〉

2. 後續追蹤

23〈不受軍事審判 & 居住遷徙自由〉講綱

軍審法修正（102/08/13）（洪仲秋案之後）

§1-II：

「現役軍人非戰時犯下列之罪者，依刑事訴訟法追訴、處罰：

- 一、陸海空軍刑法第四十四條至第四十六條及第七十六條第一項。
- 二、前款以外陸海空軍刑法或其特別法之罪。」

§34：

「犯罪事實之一部應依刑事訴訟法追訴、審判時，全部依刑事訴訟法追訴、審判之。」

貳、居住遷徙自由

一、比較憲法例（權利內涵）

1. ECHR

1.1 Protocol 4

§2: 凡合法入境者，皆應享有自由遷徙及自由選擇住居之權（right to liberty of movement & freedom to choose residence）

1.2 Protocol 4

§3: 禁止驅逐國民出境（prohibition of expulsion of nationals），國民並有返國之權

1.3 Protocol 4

§4: 禁止集體驅逐外國人出境（prohibition of collective expulsion of aliens）

1.4 Protocol 7

§1: 驅逐外國人出境之正當程序（procedural safeguards

relating to expulsion of aliens) 

2. UK_WC

§16 遷徙自由 (Freedom of Movement)

16.1 Everyone lawfully within the United Kingdom has the right of liberty of movement and freedom to choose their residence within the United Kingdom.

合法居留者（含外國人在內）皆有居住、遷徙之自由
（Cf. 釋字 710）

16.2 Everyone is free to leave the United Kingdom, and everyone holding British nationality is entitled to a passport.
任何人得自由離境，國民並有請求發給護照之權

16.3 No restrictions shall be placed on the exercise of the rights set out in this Article other than such as are in accordance with law and are necessary in a democratic society- 限制之限制（要件）

.1 in the interest of national security, public safety or the preservation of public order; or

.2 for the prevention of crime or under an order imposed by a court on conviction of crime; or

.3 for the protection of health; or

.4 for the protection of the rights and freedoms of others.

16.4 The rights set out in paragraph 1 may also be subject, in particular areas, to restrictions imposed in accordance with law and justified by the public interest in a democratic society.

第一項之自由得以民主社會之公共利益為由，在某些地

23〈不受軍事審判 & 居住遷徙自由〉講綱

區施予限制

§17 免於驅逐出境之自由 (Freedom from Expulsion from United Kingdom)

17.1 No British national shall be expelled from the United Kingdom or deprived of the rights to enter the United Kingdom. 不得驅逐國民出境，或拒絕其入境

17.2 非國民

17.2.1 Other persons may be expelled from the United Kingdom only in pursuance of a decision reached in accordance with law. 外國人得依法驅逐出境

17.2.2 Any such person who have been lawfully admitted to United Kingdom shall be allowed, prior to expulsion, 合法入境者，於被驅逐出境前，應

.1 to submit reasons against expulsion;

予答辯之機會（說明何以不應被驅逐）and

.2 to have their cases reviewed by, and be represented for the purpose before, the competent authority or a person or persons especially designated by the competent authority.

並許其委任代理人，及向主管機關申訴

17.3 This Articles does not prevent the extradition of persons, through established legal procedures, for the purpose of standing trial for a criminal offence or serving a sentence lawfully imposed on them in another jurisdiction.

得經法定程序，遣返回本國受審或受刑

§18 政治庇護權 (Right of Asylum)

18.1 Every person has the right to seek and be granted asylum in the United Kingdom in accordance with the law of the United Kingdom and international conventions, if they are being pursued for political offences.

因政治理由遭受訴追者，得依英國法律與國際公約，申請政治庇護

18.2 In no case may an alien be deported or returned to a country, regardless of whether or not it is their country of origin, if in that country their right to life or personal freedom is in danger of being violated because of their race, nationality, religion, social status, or political opinions. 

外國人生命或人身自由，倘於某國有因種族等原因而遭受害之虞者，不得將其驅逐出境至該國，或遣返至該國

3. Checklist/ III. Fundamental Rights

M) Freedom of movement and residence,

N) Freedom to leave and return, ban against exiles 

4. 憲法 §10：「人民有居住及遷徙之自由」

釋字 443 解釋理由書 [2]：

「憲法第十條規定人民有居住及遷徙之自由，係指人民有選擇其居住處所，營私人生活不受干預之自由，且有得依個人意願自由遷徙或旅居各地之權利」

釋字 454 解釋文：

「憲法第十條規定人民有居住及遷徙之自由，旨在保障人民有自由設定住居所、遷徙、旅行，包括出境或入境之權利」

二、「居住」的概念

23〈不受軍事審判 & 居住遷徙自由〉講綱

1. 住家即城堡（Everyone's house is his own castle）
→ 空間（物理）隱私的概念（參●30講）
 2. 居住之空間範圍 包括日常生活之家居主屋、庭園、車庫、地下室及暫時居住之旅館房間
 - 刑法 §306（侵入住宅罪）
 - 刑法 §307（違法搜索罪）
 3. 兼指民法上之「住所」與「居所」
 - 民法 §20-I（依一定事實，足認久住之意思，住於一定之地域者，即為設定住所於該地）
 - 「居所」：無久住之意思，而事實上居住之處所（如宿舍）
- 三、「居住自由」之限制（侵害）
1. 令狀主義
 - 1.1 原則：搜索須有搜索票
 - 刑訴 §128
 - 1.2 例外：無須（搜索）票搜索
 - 刑訴法 §§130, 131, 131-1
 - 行政檢查：違法出版品檢查（釋字 294）
 - 行政執行之「即時強制」：行政執行法 §§36, 39, 40
 2. 搜索之時段
禁止夜間搜索（刑訴 §§ 146-I & III, 147）
 3. 非法搜索取得證據之證據能力（刑訴 §158 之 4）
 - 3.1 毒樹果實理論（fruit of the poisonous tree doctrine）
 - 3.2 例外：
如該證據

- 可自其他獨立、無瑕疵的來源 (independent, untainted source) 獲得
- 違法蒐證與有毒證據間之因果關係過於遙遠 (too attenuated)
- 必然會被發現 (inevitable discovery)
- 搜索票雖因欠缺相當事由而無效，然執法人員確係基於善意 (good faith) 而為搜索

四、「遷徙」的概念

1. 設定、變更「住、居所」或「國籍」，屬於「居住」或「遷徙」之自由？
2. 旅行權 (right to travel) 屬 (國內、外之) 遷徙自由

五、遷徙自由的限制

1. 國內遷徙之限制
 - 1.1 特定地域之限制住居 (釋字 542)
 - 1.2 以戶籍登記為基礎的會籍管理 (釋字 398)
2. 國外遷徙 (入、出境) 之限制
 - 2.1 國民返國之自由 (釋字 454 & 558, 265)
 - 2.2 國民出境之限制
 - 欠稅者限制出境 (釋字 345)
 - 役男限制出境 (釋字 443)
 - 役男居所變更之申報限制，尚不構成居住、遷徙自由之限制 (釋字 517)
 - 2.3 大陸地區人民之出入境 (釋字 497)

23〈不受軍事審判 & 居住遷徙自由〉講綱

【學思策問】

Q 以設籍於當地達一定期間作為受領該地某種「福利金」之條件，是否侵害其居住遷徙之自由？

Q 洪仲秋案之後，軍事審判法再次修正，軍事審判業務於平時完全劃交（廣義之）司法機關處理，其得失為何？

【進階閱讀】 湯德宗，〈軍事審判法釋憲案專家學者說明會意見書〉，輯於氏著《憲法結構與動態平衡：權力分立新論・卷二》，頁 507 以下（2014 年，增訂四版）。

詹鎮榮，〈基本權各論基礎講座 (14) -- 居住自由〉，《法學講座》，第 30 期，頁 13-29（2004 年 11 月）。

Leonard B. Boudin, *The Constitutional Right to Travel*, 56 COLUM. L. REV. 47 (1956).

【課後習作】 居住遷徙自由之限制，應屬「絕對」或「相對」之法律保留事項？

版權聲明

頁碼	作品	版權標示	作者／來源
287	蓋現役軍人，本應包括於第八條所稱『人民』之內，亦受該條之各種保障，惟因本條規定之故，於其犯陸海空軍刑法或其特別法之罪時，遂不適用第八條之規定，得由軍事審判機關加以審問處罰矣		林紀東，《中華民國憲法逐條釋義》 本作品依據著作權法第46、52、65 條合理使用。
295-296	1.1 Protocol 4 §2: 凡合法入境者，皆應享有自由遷徙及自由選擇住居之權（right to liberty of movement & freedom to choose residence）1. 4 Protocol 7 §1: 驅逐外國人出境之正當程序（procedural		《European Convention on Human Rights》 本作品屬公共領域。

	safeguards relating to expulsion of aliens)		
296-298	16.1 Everyone lawfully within the United Kingdom has the right of liberty of movement and freedom to choose their residence within the United Kingdom.....or personal freedom is in danger of being violated because of their race, nationality, religion, social status, or political opinions.		The Institute for Public Policy Research , 《The Constitution of the United Kingdom》 P54-56 (http://www.ippr.org/files/images/media/files/publication/2014/01/the-constitution-of-the-united-kingdom_1991-2014_1420.pdf?noredirect=1) 瀏覽日期：2016/10/6， 本作品依據著作權法第46、52、65 條合理使用。
298	III. Fundamental Rights M) Freedom of movement and residence, N) Freedom to leave and return, ban against exiles		Albert P. Blaustein , 《Framing the Modern Constitution: A Checklist》 本作品依據著作權法第46、52、65 條合理使用。